

0012105-68.2016.8.26.0577

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Especializada no combate ao tráfico de entorpecente, apurou-se acerca do tráfico de drogas em tela. Assim, com base também em regular interceptação telefônica foi observado que os réus agiam de forma contínua, associada e coordenada, com divisão de tarefas, visando o tráfico de drogas. Destacou-se que os réus Wellington e Wanderley eram os responsáveis pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0012105-68.2016.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012105-68.2016.8.26.0577

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 216/2016 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de São José dos Campos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Nogueira de Toledo Silva e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1. BRUNO NOGUEIRA DE TOLEDO SILVA, AILTON ALVES DE SOUZA, WANDERLEY CAETANO VENÂNCIO e WELLINGTON RODRIGUES VENÂNCIO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 35, da Lei 11.343/06, porque na data e local descritos na denúncia, agindo com consciência e vontade livres, associaram-se para o fim de cometerem tráfico ilícito de drogas, de forma reiterada ou não, bem como foram denunciados como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/06, por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, do Código Penal, porque na data e local descritos na denúncia, agindo com consciência e vontades livres, guardavam e tinham em depósito, para entrega a terceiros, respectivamente, 58 invólucros de maconha, 118 cápsulas de cocaína, 91 pedras de crack, mais uma pedra e fragmentos também de crack, bem como 29,4 gramas de cocaína em pó e 2,1 gramas de

cocaína em pedra, popularmente conhecida como crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e WANDERLEY CAETANO VENÂNCIO e WELLINGTON RODRIGUES VENÂNCIO, qualificados nos autos, foram denunciados também como incurso no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, porque na data e local descritos na denúncia possuíam arma de fogo com numeração suprimida, no caso, um revólver calibre 38, marca Taurus, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados, apresentando defesa prévia.

Recebida a denúncia, foram os réus citados.

Em audiência de instrução debates e julgamento, realizada por videoconferência, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, interrogando-se, enfim, os réus.

Em debates, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a conseqüente condenação dos réus. A defesa, preliminarmente, requereu a nulidade do feito em de irregularidades na interceptação telefônica que deu origem ao presente, bem como por ilegalidade da prisão em flagrante. No mérito, pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com a redução máxima prevista na Lei de Drogas, substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, com reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

2.A preliminar deve ser rejeitada.

Muito embora o esforço da combativa defesa, não há falar em nulidade da interceptação telefônica em apenso e conseqüentemente deste feito, tendo em vista que a medida cautelar observou todos os ditames legais para tanto, uma vez que se baseou e diligentes investigações prévias por parte da polícia civil, não sendo necessário para tanto eventual documentação pormenorizada destas. Além disso, cumpre notar que o flagrante foi formalmente em ordem, ocorrendo a certeza visual do crime, nos termos do artigo 302, do Código Penal, não sendo demais lembrar o domínio do fato, consoante, aliás, se observará adiante, confundindo-se o mais com mérito, ocasião em que será analisado.

Em apenso, autos 0004982-19.2016.8.26.0577 de interceptação telefônica que deram origem ao presente.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls., que teve resultado positivo para maconha e cocaína, não merecendo reparo, pois bem se utilizou da boa técnica existente.

A autoria é indubitosa.

Os réus Bruno, Ailton e Wanderley negaram os fatos descritos na denúncia. Em apertada síntese, deram conta que a droga em tela lhes não pertenciam, não tendo qualquer envolvimento com o tráfico.

Já o réu Wellington disse que realmente estava a guardar drogas para o tráfico, mas negou participar de qualquer associação criminosa para tanto, isentando a participação dos demais réus neste fato.

Tal versão, contudo, lhes não aproveita, pois além de pouco crível, notadamente na parte que o corréu tenta deliberadamente isentar a responsabilização dos demais, não encontrando, no mais, respaldo nas provas produzidas à luz do contraditório.

O conjunto probatório, todavia, corroborou os fatos descritos na denúncia.

As testemunhas ouvidas, notadamente os policiais civis, de maneira firme e coerente, em especial o Digníssimo Delegado de Polícia, Dr. Darcy Ribeiro, de maneira firme e coerente, informaram que em minucioso trabalho de campo da equipe da DISE, Delegacia Especializada no combate ao tráfico de entorpecente, apurou-se acerca do tráfico de drogas em tela. Assim, com base também em regular interceptação telefônica foi observado que os réus agiam de forma contínua, associada e coordenada, com divisão de tarefas, visando o tráfico de drogas.

Destacou-se que os réus Wellington e Wanderley eram os responsáveis pela preparação, embalagem e abastecimento direto de drogas nas biqueiras, pontos ilegais de venda deste material ilícito, ao passo que os corréus Ailton e Bruno eram os responsáveis pelo fornecimento e reposição de drogas para a organização, sendo que Ailton era um lugar-tenente, fazendo a intermediação do demais, Wellington e Wanderley, com Bruno, o chefe da associação, que finalmente providenciava a droga para subsidiar o comércio ilegal, mantendo assim o círculo criminoso, com obtenção de fundos, preservado. Diante disso, de posse de regulares mandados de busca e apreensão, foi feita uma primeira incursão, encontrando R\$ 3.700,00 e parte das drogas descritas na denúncia na residência de Wellington e Wanderley, que lograram fugir neste momento. Além disso, na residência de ambos havia a arma de fogo descrita na inicial, ao passo que na casa de Bruno havia R\$ 32.929,00 produto desta nefasta atividade ilegal. Já em um segundo momento, foram os réus Wanderley e Wellington encontrados em sua residência, na posse de R\$ 190,00 e do restante das drogas em tela.

As demais testemunhas ouvidas, arroladas exclusivamente pela defesa, pouco ou nada acrescentaram ao conjunto probatório, limitando-se a prestar detalhes abonadores da vida pregressa dos réus, pois não presenciaram e/ou não souberam precisar detalhes desta operação policial.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório é mais que suficiente para autorizar a condenação pelos delitos previstos nos artigos 33, 35, da Lei 11.343/06, percebendo-se que os corréus praticaram as condutas típicas, em suas elementares.

O conceito de suficiência, não se confunde, para efeito de condenação, com isenção total de eiva indubitativa, consiste, pois, na firme possibilidade de afirmação da realidade do fato imputado e de definição de sua autoria, no contexto das comprimidas fronteiras humanas da capacidade de apreensão dos elementos probatórios e de reconstituição do episódio delituoso. Prova suficiente não é nem pode ser penhor de certeza plena, de que somente os deuses são senhores. Daí se afigura irreal e meramente retórico o emprego de expressões como “prova categórica”, “prova cabal”, e outras do gênero.

Bem assim, há prova suficiente de que a substância entorpecente foi encontrada em poder dos réus, o que, por si só, autoriza a condenação, ressaltando-se, aqui, ser desnecessário qualquer mandado judicial, pois se trata de flagrante por crime permanente.

Autoriza porque, desta forma, os réus praticaram a conduta típica prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, incidindo em pelo menos três dos verbos descritos na figura típica, qual seja, “ter em depósito”.

O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/03, ou seja, o uso próprio.

Mas, mesmo se assim não fosse, o fim de mercancia ilícita, está demonstrada ante as peculiaridades do caso, ou melhor, a enorme quantidade de entorpecente encontrado, a forma como estava separado e acondicionado, as interceptações telefônicas dando conta da traficância no sítio dos eventos, o encontro de considerável quantidade de dinheiro e a confissão informal, apontam para fins de comercialização, para repasse a terceiros, em forma associativa.

O fato da substância entorpecente ter sido encontrada em poder dos réus, inverte o ônus da prova, impondo-lhes justificativa verossímil, fazendo incidir sobre eles presunção de culpabilidade.

No caso presente, os réus não fizeram prova suficiente nesse sentido, pois se invertendo o ônus da prova, a suficiência probatória, agora para afastar ou, pelo menos, estabelecer a dúvida sobre a acusação, compete a eles.

Não se diga que o testemunho de policiais deva ser recebido com reservas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pelo contrário, o testemunho de policiais deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que eles, credenciados pelo Estado para atuarem na repressão e na prevenção delitiva, sejam desconsiderados, quando compromissados, como qualquer outra testemunha, que vêm a

juízo relatar diligências a que procederam no exercício de suas funções. Por outro lado, não obstante o entorpecente não tenha sido encontrado em poder direto de alguns dos réus, também responsáveis pelo crime são, pois o guardavam da mesma forma que os demais corréus, uma vez que coautores. Quanto à coautoria, frise-se que, nos termos do artigo 29, "caput", do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominada, na medida de sua culpabilidade.

"Co-autoria 'é a realização conjunta de um delito por várias pessoas que colaboram consciente e voluntariamente' (Muñoz Conde, Teoría General del Delito, 1984, pg. 292). Cada co-autor é um autor e, por isso, deve apresentar as características próprias do autor. Isto significa que o co-autor 'é aquele autor que tem o domínio da realização do fato conjuntamente com outro ou outros autores, com os quais tem um plano comum e uma distribuições de funções na realização do mútuo acordo' (Juan Bustos Ramírez, Manual de Derecho Penal Español, 1984, pg. 331)".

"A co-autoria é nada mais nada menos, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela sobre o princípio da divisão do trabalho; cada autor colabora com sua parte no fato, a parte dos demais, na totalidade do delito e, por isso, responde pelo todo. Há na co-autoria, a decisão comum para a realização do resultado e a execução da conduta".

Diante do conjunto probatório, tudo leva a crer que os co-réus são co-autores, porque, de qualquer modo, contribuíram para o crime, estando previamente associados entre si e com unidade de propósitos, tendo o domínio final do fato típico, o qual praticaram, não podendo ser considerados como meros partícipes, vez que nenhum deles simplesmente apenas contribuiu auxiliando a conduta do outro.

Ora, tal coautoria comprovada está pelos depoimentos dos policiais, já analisados, onde se percebe, evidentemente que os réus, associados, faziam do tráfico seu meio de vida, bem como, mesmo se isso não bastasse, em razão da já mencionada interceptação telefônica guardavam droga para fins de revenda, do que denota serem os réus verdadeiros traficante, associados, como já asseverado, para praticar o nefasto crime que assola nossa sociedade.

Quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/703 de se dizer que, da mesma forma e com a mesma suficiência, demonstrado está.

Como se sabe, não é o simples concurso de pessoas que caracteriza associação.

Necessário é o "animus" associativo prévio, sem dúvida uma "societas sceleris".

Necessária é a comprovação de tal elemento do tipo, ou seja, vínculo associativo de caráter permanente, duradouro, que se depreende de vários elementos tais como reuniões prévias, base de operação, níveis de lucros presumidos, etc., o que corre nos autos, tudo comprovado pelos já referidos e analisados depoimento policiais e, também, pelos documentos mencionados em interceptação telefônica, os quais demonstram ser profissional e reiterado o tráfico realizado pelos réus.

Nesse sentido, jurisprudência:

"O crime do artigo 14, da Lei 6.368/76, exige, como um dos seus elementos, vínculo associativo que se não comprova tão somente com mera atividade comum dos agentes, evidenciando-se outrossim com sua atuação conjugada".

"O artigo 14 da Lei de Tóxicos é autônomo, bastando para sua consumação que haja a formação do bando para a prática do tráfico de entorpecentes. Basta, para configurá-lo, a organização do bando. Não se identifica ele com a qualificadora prevista no artigo 18, III, da mesma lei, que consiste em ter o crime previsto na lei aludida sido praticado por duas ou mais pessoas".

Ainda, necessário frisar que os corréus, mediante mais de uma ação, com desígnios diversos, praticaram dois crimes distintos, quais sejam, os previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, sendo, de rigor, portanto, o reconhecimento do concurso material, nos termos do artigo 69, "caput", do Código Penal.

Nesse sentido, jurisprudência:

"O crime previsto no artigo 14 da Lei de Tóxicos (Lei 6.368/76), isto é, associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos seus arts. 12 ou 13, é ilícito autônomo e, portanto, punível, em concurso material, com qualquer dos outros crimes tipificados naqueles dois artigos. A qualificação de que trata o inc. III do art. 18 da Lei de Tóxicos,

diferentemente, se dá quando a associação é eventual, decorrendo de reunião ocasional, sem que haja uma quadrilha organizada previamente, em conluio de previsão duradoura”

“O crime de associação previsto no art. 14 da Lei Antitóxicos configura-se com o simples fato da associação, sem necessidade de que sejam concretizados os delitos visados pelos parceiros ou sócios para integração de sua potencialidade perigosa, não se exigindo exteriorização de seu fim específico. Se a associação criminosa, já constituída e penalmente relevante, concretiza seus propósitos, há concurso material de infrações”

Neste ponto, bom observar que, de outra banda, o crime de tráfico ilegal de drogas, no caso dos autos, é único, pois muito embora as apreensões tenham ocorrido em dois momentos distintos, referem-se a apenas um contexto, dividido em atos, não sendo demais lembrar se tratar de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado.

Ainda, em razão das peculiaridades do caso, tudo leva a crer que o dinheiro encontrado era produto do ilícito, não se logrando provar o contrário, ou seja, sua origem lícita, sendo de rigor seu perdimento a favor da União, como efeito da condenação, nos termos do artigo 91, II, “b”, do Código Penal.

Por fim, indefiro o pedido de perdimento do veículo apreendido, pois, muito embora o fato deduzido de forma incontroversa de que os réus faziam do tráfico seu meio de vida, não houve prova específica de que os veículos em questão seriam utilizados reiteradamente para tal fim. Porém, indefiro eventual pedido de liberação do veículo feito pela defesa, uma vez que deve sê-lo por via e em momento próprios, não sendo demais lembrar que ainda não há trânsito em julgado desta decisão contrária ao pedido ministerial de perda do bem.

Por outro lado, percebe-se que os réus Wellington e Wanderley também praticaram, com desígnios diversos em concurso material, a conduta típica prevista no artigo 16, parágrafo único IV, Lei 10.826/03, pois portava arma de fogo, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar em razão de não possuir porte ou registro do bem.

Há que se dizer, por primeiro, ser suficiente para a caracterização do crime a simples conduta típica, no caso, portar, tendo em vista que delito é de natureza formal e de perigo presumido, ou melhor, do simples porte presume-se o perigo que a sociedade está exposta, não importando as reais intenções do agente, ou seja, se, por exemplo, portava a arma para se defender, não tendo intenção de praticar qualquer delito.

Não se diga, uma vez mais, que o testemunho de policiais deva ser recebido com reservas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pelo contrário, o testemunho de policiais deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que eles, credenciados pelo Estado para atuarem na repressão e na prevenção delitiva, sejam desconsiderados, quando compromissados, como qualquer outra testemunha, que vêm a juízo relatar diligências a que procederam no exercício de suas funções.

Neste ponto, necessário se fazer algumas considerações sobre a Lei 10.826/03, que atualmente disciplina a matéria.

A melhor inteligência dos artigos 30 e 32, da Lei 10.826/03, aponta que o legislador protege a posse e propriedades lícitas de armas de fogo, capazes de regular comprovação, demonstrando-se, então, estarem de acordo com o SINARM e passíveis, portanto, de registro.

Ainda, em complementação ao acima asseverado, de se ressaltar que o artigo 32, da Lei 10.826/03, “a priori”, se aplica exclusivamente nas hipóteses já mencionadas. A princípio, portanto, o referido diploma legal não protege o possuidor da arma de fogo insuscetível de registro, como a arma de fogo com numeração raspada, exatamente o caso dos autos.

Porém, não há como negar que o mencionado artigo 32, da Lei 10.826/03, cria uma presunção de boa-fé, incentivando o desarmamento da população, independentemente da origem da arma de fogo que se tem em sua posse, devendo-se apenas comprovar a real intenção de devolução, através de todos os meios admitidos em direito, notadamente com a apresentação de regular autorização expedida pela autoridade competente, o que poderia, aí sim, e somente nesta situação, apontar, em tese, eventual

atipicidade da conduta, o que, "data máxima venia" não ocorre no presente caso. De outra banda, a capitulação, quanto ao porte de arma, está correta, porque, não obstante não tenha o legislador se utilizado da melhor técnica, repetiu, aqui, em parte, a redação da Lei 9.437/97, ou seja, quando há a menção a supressão de numeração da arma, refere-se a Lei, como já dito supra, a qualquer arma, quer de uso permitido, quer de uso restrito, consistindo em um tipo penal autônomo. Aqui, também de se ressaltar que, ao contrário do que acontecia na vigência da Lei 9.437/97, não há necessidade de comprovação da efetiva supressão da numeração da arma por parte do réu, uma vez que a redação presumiu o perigo, dando o vetor da gravidade do delito, pelo simples fato do porte de arma com numeração raspada, fato que, como já analisado está demonstrado, à exaustão nos autos. Destarte, demonstradas a materialidade e a autoria, nos termos da fundamentação supra, impõe-se a condenação. Na aplicação da pena, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, as penas-bases devem aumentadas em um terço, tendo em vista serem os réus reincidentes, reincidentes específicos e portadores de maus antecedentes, conforme certidão de fls., tornando-se, assim, definitiva, na ausência de outras condições modificadoras. Aqui, bom ressaltar que, quanto ao delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, não há falar na causa especial de redução de pena, tendo em vista estar evidente que os agentes se dedicam à atividade criminosa, tanto que também condenados pelo delito de associação previsto no artigo 35, do mesmo estatuto legal, não sendo demais lembrar serem eles reincidentes, específicos alguns deles, inclusive. Essa pena assim deve ser tornada definitiva, na ausência de outras condições modificadoras. Em razão das condições econômicas dos réus, a unidade do dia multa deve ser fixada no mínimo legal, aplicando-se a prevista na Lei de Tóxicos, tendo em vista o princípio da especialidade.

3. Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e

CONDENO os réus WANDERLEY CAETANO VENÂNCIO e WELLINGTON RODRIGUES VENÂNCIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, com unidade fixada no mínimo legal; como incursos no artigo 35, da Lei 11.343/06, à pena de quatro anos de reclusão e novecentos e trinta e três dias multa, com unidade fixada no mínimo legal; e como incurso no artigo 16, parágrafo único, IV, Lei 10.826/03, à pena de quatro anos de reclusão e treze dias-multa, com unidade fixada no mínimo legal. Essas penas devem ser aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 69, "caput", do Código Penal.

CONDENO os réus BRUNO NOGUEIRA DE TOLEDO SILVA e AILTON ALVES DE SOUZA, qualificados nos autos, como incursos no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, com unidade fixada no mínimo legal; e, como incursos no artigo 35, da Lei 11.343/06, à pena de quatro anos de reclusão e novecentos e trinta e três dias multa, com unidade fixada no mínimo legal. As penas devem ser aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 69, "caput", do Código Penal.

Não fazem os réus jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, do Código Penal, pois o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado inclusive ao hediondo. Mesmo se isso não bastasse, o delito em questão está capitulado em Lei Especial (nº 11.343/06), e tal, em seu artigo 33, § 4º, veda expressamente o aludido benefício, isso sem dizer, no caso, é claro, da quantidade de pena aplicada e do concurso material de graves crimes, por réus reincidentes.

Aqui, bom ressaltar que, no meu sentir, tal dispositivo não é inconstitucional, pois, sem embargo das opiniões em contrário, observa o princípio da individualização da pena e, assim, considerando ser o crime mais grave a ele impede a substituição da pena.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial para cumprimento das penas deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada, mas notada e precipuamente, porque assim recomendam os elementos concretos e individualizados, ante a gravidade do tráfico em questão, que na situação concreta, não provém de simples abstrações, suposições ou meras presunções, mas, sim, da situação fática descrita na denúncia, consistente na apreensão de diversos pinos de cocaína e invólucros de maconha, juntamente com considerável quantidade de dinheiro, droga essa destinada ao abastecimento de ponto de droga nesta região, por associação criminosa destinada a tal fim com membros reincidentes específicos, o que não só põe em relevo a periculosidade do agente, como também justifica e autoriza regime inicial mais gravoso.

Contudo, muito embora a gravidade dos delitos, tendo em vista que os réus responderam soltos a este crime, não prejudicando a instrução criminal e nem impedindo a aplicação da Lei Penal, fazem eles jus ao benefício de recorrer em liberdade.

Determino, ainda, o perdimento, a favor da União, do dinheiro apreendido, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal, devendo-se ser entregue ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, procedendo-se nos termos do artigo 60 e seguintes, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 04 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA